

1501781-34.2022.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Jane Rute Nalini Anderson

Comarca: Jundiaí / SP

Foro: Foro de Jundiaí

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/09/2022

... e acondicionadas para a venda no varejo, configurando o tráfico ilícito de drogas.

A conduta de qualquer dos verbos contidos no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, implica em tráfico, sendo o dolo sempre genérico. Por isso, dispensável a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga, sendo bastante a prova do conjunto de indícios e presunções ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí

Cartório da 3ª. Vara Criminal: Largo São Bento, s/nº, Centro, Jundiaí, Estado de São Paulo.

CEP nº 13201-035. Telefone: (11) (11) 2136-6223, E-mail: jundiai3cr@tjsp.jus.br.

Processo nº 1501781-34.2022.8.26.0544

Página nº de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí

Cartório da 3ª. Vara Criminal: Largo São Bento, s/nº, Centro, Jundiaí, Estado de São Paulo.

CEP nº 13201-035. Telefone: (11) 2136-6223, E-mail: jundiai3cr@tjsp.jus.br.

Processo nº 1501781-34.2022.8.26.0544

Página nº de

Vistos.

EVERTON MARTINS GOMES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos artigos 33 da Lei nº 11.343/06 e 333 do Código Penal, em concurso material, porque no dia 12 de julho de 2022, por volta de 15h30min, na Rua Bastos, altura do numeral 171, Jardim Tamoio, nesta cidade e Comarca de Jundiaí, trazia consigo e guardava as substâncias tóxicas descritas na denúncia, que causam dependência física e

psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta, outrossim, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o acusado, ofereceu vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a omitir ato de ofício. Narra a peça inicial que, na data dos fatos, o réu recebeu diversas porções de tóxico de terceiros e as colocou em uma bolsa, levando-as consigo até o endereço acima descrito, com objetivo de comercializá-las.

Ocorre que guardas municipais realizavam patrulhamento no local e avistaram Everton em atitude suspeita, carregando em seu pescoço um rádio comunicador e em poder da sacola. Por tal motivo, resolveram interceptá-lo.

Em poder do réu, além do referido rádio comunicador, foram apreendidas, no interior da sacola, 21 porções de maconha, 16 porções de cocaína e a quantia de R\$ 439,25, em cédulas de valores diversos.

Na mesma data, o réu foi visto por policiais civis, que já estavam cientes de que o mesmo estava levando drogas para Itupeva para abastecer "biqueiras".

Em seguida, o acusado admitiu a traficância e ofereceu aos agentes municipais a importância de R\$ 5.000,00 para que o liberassem, afirmando que precisaria apenas fazer uma ligação com seu celular.

Assim, pela quantidade das substâncias entorpecentes e circunstâncias das apreensões, foi preso em flagrante.

Recebida a denúncia, foi o réu citado e intimado para responder à acusação.

Apresentada a defesa, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento.

Na instrução ouviram-se duas testemunhas, após o que o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em debates, o Promotor de Justiça, após analisar as provas, pediu a condenação do réu nos exatos termos da denúncia, porquanto devidamente demonstradas a autoria e a materialidade delitivas. Requereu, ainda, a observância dos maus antecedentes e reincidência, com preponderância desta última em relação à atenuante da confissão e imposição de regime inicial fechado.

A defesa, arguiu, em preliminar, a nulidade da atuação dos guardas municipais, vez que não havia fundada suspeita a embasar a abordagem policial, sendo de rigor a absolvição do réu. Alternativamente, pediu a fixação da pena-base no patamar mínimo; aumento mínimo em razão da reincidência e sua compensação com a atenuante da confissão.

RELATADO.

DECIDO.

A preliminar suscitada não merece guarida.

Com efeito, não há falar em nulidade na abordagem do réu realizada pelos guardas municipais, vez que quando esses agentes interceptam qualquer cidadão em local público e dentro dos limites legais, respeitando os direitos daquele submetido à revista pessoal, não há que se falar em nulidade, vez que se trata de atitude que faz parte da obrigação legal dos agentes da autoridade. Além do mais, esses agentes não podem se omitir diante de qualquer situação em que se vislumbra eventual prática de crime.

Nesse teor, "(...) 3. A abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública. 4. Hipótese em que a ação dos policiais foi efetiva, pois resultou na prisão em flagrante do paciente por crime permanente, o qual não se exige mandado de busca e apreensão para sua efetivação. Precedentes. 5. De acordo com a Quinta Turma deste Tribunal, "revela-se despropositado que, a toda abordagem policial, o agente estatal advirta acerca do direito constitucional ao silêncio, sob pena de torná-los todos em suspeitos de práticas delitivas" (RHC 61.754/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 07/11/2016). 6. No caso em exame, o acórdão impugnado afirmou que "tanto no interrogatório realizado na fase investigativa quanto naquele posteriormente efetivado em juízo, houve expressa menção acerca da advertência do direito ao silêncio", razão pela qual não há falar em cerceamento de defesa. 7. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige a demonstração do prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio *pas de nullité sans grief*, o que não se verifica na espécie. 8. Habeas corpus não conhecido" (STJ, HC nº 385.110/SC, Rel. Ministro

Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 14/06/2017).

Não há, portanto, nulidade ou irregularidade na abordagem policial que ensejou a presente ação penal.

Importante observar, outrossim, que, no caso dos autos, não foram extrapoladas as funções típicas da Guarda Municipal.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a busca e apreensão feita a partir de fundada suspeita de flagrância, nos termos do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, é permitida à Guarda Civil Municipal, não havendo abuso de função.

Nesse sentido, "1. A primeira parte do art. 301 do Código de Processo Penal autoriza a qualquer do povo prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Desse modo, inexiste ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas municipais. 2. Conforme compreensão da Sexta Turma desta Corte Superior, havendo fundada suspeita a configurar situação de flagrante delito, mostra-se lícita a abordagem pessoal feita pela Guarda Civil Municipal, que não atua, nessa hipótese, como polícia investigativa. 3. Agravo regimental desprovido" (AgRg no HC nº 667.413/SP, 6ª Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe de 16/6/2021).

E mais, "(...) Contudo, também é firme o entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, "nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, razão pela qual não há qualquer óbice à sua realização por guardas municipais. Precedentes" (HC n. 357.725/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 12/05/2017). Precedentes. III - Destarte, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado v. aresto reprochado, bem como no auto de prisão em flagrante lavrado pela autoridade policial, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal. Ademais, no que tange ao pleito defensivo de reconhecimento da ilicitude das provas, verifica-se que o v. aresto vergastado afastou motivadamente a alegada nulidade da busca e apreensão pessoal, sob o fundamento de que havia fundada suspeita para a referida diligência porquanto, em patrulhamento de rotina em local conhecido pelo tráfico de drogas (cracolândia), os guardas civis visualizaram o acusado em atitude suspeita, uma vez que tentou empreender fuga ao se deparar com a viatura, levando à abordagem que resultou na apreensão de entorpecentes de natureza extremamente deletéria. Precedentes" (STJ, HC 742.941/SP, 5ª Turma, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado), DJe 16/08/2022).

Ressalte-se, outrossim, que o inquérito é mero procedimento administrativo-informativo, razão pela qual as investigações realizadas pela autoridade policial não se confundem com instrução criminal, motivo pelo qual eventuais irregularidades por ventura nele ocorridas, não são capazes de ensejar nulidade do processo, o qual, no caso em análise, transcorreu de forma regular e sem vícios

Oportuno, ainda, frisar que "em processo penal, vigoram os princípios de que 'nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa (art. 563 do CPP)" (STJ 5ª Turma, RHC nº 38.424/MG, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 07/03/2005).

Afastada a preliminar, no mérito a materialidade está devidamente demonstrada pelo auto de exibição e apreensão das drogas, do rádio comunicador e do dinheiro (fls. 11), bem como pelos laudos de exame químico-toxicológico, provisório e definitivo (fls. 13/16, 126/129 e 136/138), os quais confirmam que as substâncias apreendidas são entorpecentes que causam dependência física e psíquica e pelos demais documentos acostados aos autos.

Incontroversa a prova de autoria.

Na fase administrativa, o réu preferiu o silêncio. Em Juízo, confessou serem parcialmente verdadeiros os fatos, admitindo que estava na posse das drogas, mas não estava vendendo-as. Era responsável por entregar os entorpecentes para "Carlos" e, para tanto, receberia a quantia de R\$ 150,00. Negou ter oferecido dinheiro aos guardas municipais, vez que tinha dívida com um traficante. Não tinha conhecimento do conteúdo da bolsa que carregava. O rádio comunicador serviria para ser avisado da chegada de "Carlos". Não conhecia os guardas que efetuaram sua prisão e nada tinha contra eles.

Sucedee, porém, que tal versão restou isolada nos autos e não merece credibilidade. Corroborando a prova de autoria, as testemunhas Fernando Miguel Franco Tafarello e Edwin Ricardo Barbosa, guardas municipais que tomaram parte nas diligências, sempre que ouvidas, narraram como se deu o encontro das substâncias tóxicas, do rádio comunicador e do dinheiro em poder do réu, em local conhecido como ponto de tráfico. Relataram, ainda, que o réu ofereceu vantagem indevida para não ser preso. Não conheciam o acusado antes dos fatos.

As palavras dessas testemunhas, ao contrário do alegado pela defesa, são suficientes para corroborar a acusação. São depoimentos coerentes, harmônicos e verossimilhantes, que não demonstram o propósito de querer enganar nem dão motivo de suspeição. Como seu valor não se põe em dúvida, eles podem ser considerados fonte de convicção (ver: CF, 93, IX; CPP, artigo 155, caput; RTJ, 143/160 e 201/637).

Quando não bastasse, em casos de aplicação da Lei de Drogas, a jurisprudência amplamente majoritária não tem feito restrição ao testemunho de qualquer policial, quando o seu depoimento estiver em harmonia com os demais elementos de prova. Nesse sentido, "A prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado. É preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas" (STF, HC 74.522-9/AC, 2ª Turma, rel. Min. Maurício Corrêa, DJU, 13/12/96, pág. 50.167).

Note-se, agora, que as substâncias tóxicas foram apreendidas divididas e acondicionadas para a venda no varejo, configurando o tráfico ilícito de drogas. A conduta de qualquer dos verbos contidos no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, implica em tráfico, sendo o dolo sempre genérico. Por isso, dispensável a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga, sendo bastante a prova do conjunto de indícios e presunções envolvendo o acusado.

É possível, em consequência, o uso de prova indiciária, a qual também está em harmonia com o princípio do livre convencimento do juiz (cf. artigos 239 e 157, ambos do Código de Processo Penal).

Devidamente comprovada, ainda, a prática do delito tipificado no artigo 333 do Código Penal. Com efeito, trata-se de crime formal, que independe da efetiva vantagem, pois se aperfeiçoa com a mera promessa do proveito para que o funcionário público pratique, omita ou retarde ato de ofício.

Nesse teor, "No delito de corrupção ativa, crime formal, é irrelevante o fato de o sujeito ativo não ter a quantia oferecida ou prometida indevidamente ao funcionário público, vez que tal delito se consuma com a simples promessa de vantagem indevida e seu exaurimento se dá no instante em que o servidor toma conhecimento da oferta ou da promessa, conforme interpretação do art. 333 do CP" (RT, 771/592).

Concluindo, o conjunto probatório amealhado aos autos se mostra suficiente para dar credibilidade à acusação.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o réu EVERTON MARTINS GOMES, qualificado nos autos, como incurso nos artigos 33 da Lei nº 11.343/06 e 333 do Código Penal, em concurso material.

Passo à dosimetria das penas.

Observando os elementos norteadores contidos nos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/06, bem como levando-se em conta que o réu é portador de maus antecedentes (certidão de fls. 85/88), fixo a pena-base, para ambos os delitos, acima dos patamares mínimos, no percentual de 1/6 (um sexto), somando 2 (dois) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) diárias para o delito de corrupção ativa e 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa para o delito de tráfico, fixado cada dia-multa no mínimo previsto em lei.

Possível o reconhecimento da atenuante da confissão, mesmo que parcial, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "in verbis", "(...) 2. Tendo o paciente reconhecido seu envolvimento no delito, pois confessou parcialmente sua participação, dizendo que fez coisa errada, mas negando ter encostado a mão nas vítimas, deve haver a incidência da atenuante da confissão. 3. Nos termos da Súmula

545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para motivar a sua condenação (AgRg no AgRg no HC n. 700.192/SC, Ministro Olindo Menezes - Desembargador convocado do TRF/1ª Região, Sexta Turma, DJe 21/2/2022). O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada" (AgRg no HC n. 736.096/SP, 6ª Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 15/08/2022).

Assim, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão. Observe-se que, havendo mais de uma condenação com trânsito em julgado anterior à prática do delito em julgamento, nada impede que uma delas seja considerada como reincidência, servindo a outra como maus antecedentes.

Neste teor, já deixou assentado o Pretório Excelso que: "3. Nada impede que condenações distintas dêem ensejo a valorações distintas, porquanto oriunda de fatos distintos. 4. Não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado, pois o paciente possui mais de uma condenação definitiva, sendo possível utilizar uma para considerar negativos os antecedentes e a outra como agravante da reincidência, inexistindo bis in idem" (2ª Turma, HC nº 99.044/SP, relª. Ministra Ellen Gracie, DJe de 21/05/10).

Ante o concurso material de crimes, as sanções são somadas, tornando-se definitivas em 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 594 (quinhentos e noventa e quatro) dias-multa.

Não é caso de aplicação da causa especial de diminuição, prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, tendo em vista a dedicação do acusado à atividade criminosa (cf. STF, 2ª Turma, HC 115.101/MG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe- 186, 23/09/2013), além de seus maus antecedentes e reincidência.

A pena privativa de liberdade imposta aos delitos de tráfico e corrupção ativa será cumprida em regime fechado, uma vez que se trata de crime gravíssimo, eis que a real intenção do traficante é amealhar o maior número de vítimas, comprometendo toda a sociedade, além de se tratar de réu portador de maus antecedentes e reincidente.

Observe-se, por oportuno que mesmo a fixação da pena-base no mínimo legal cominado a espécie não é fator determinante para o estabelecimento do regime inicial de cumprimento de pena.

Analisando a última parte do artigo em comento "estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime" tem-se que o regime inicial fechado é o único satisfatório em relação à gravidade objetiva do fato, uma vez que a conduta do acusado colocou em risco, não apenas a saúde do usuário, mas, também, a integridade de toda a sociedade.

Também ante a reincidência e os maus antecedentes, inaplicável a Súmula 269 do E. Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Nesse sentido, julgado daquela Corte Superior. "(...) V - Sendo a paciente reincidente e portadora de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), o regime fechado mostra-se o mais adequado, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, não sendo aplicável a Súmula n. 269/STJ: "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". (...) (HC nº 578.638/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª Turma, DJe 03/06/2020).

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, vez que continuam presentes os requisitos autorizadores de sua custódia cautelar.

Recomende-se o réu no presídio em que se encontra.

Assim, fica o réu EVERTON MARTINS GOMES, condenado à pena de em 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 594 (quinhentos e noventa e quatro) dias-multa), como incurso nos artigos 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 e 333 do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo Diploma Legal.

Após o trânsito em julgado, seja o nome do réu lançado no rol dos culpados.

P.I.C.

Jundiaí, 05 de setembro de 2022.

Jane Rute Nalini Anderson
Juíza de Direito